

1502062-47.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502062-47.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502062-47.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3025136/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 16960895 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MARCELO DAS CHAGAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

FERNANDO MARCELO DAS CHAGAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para consumo pessoal, substância entorpecente a qual provoca dependência física e psíquica (1,4 gramas da droga conhecida como MACONHA), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de fls. 47/48, foi recebida em 25 de maio de 2022.

O feito foi desmembrado em relação a LEONARDO (fls. 129).

O réu foi citado (fls. 142/143), apresentando defesa prévia (fls. 154).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação, e o réu foi interrogado (fls. 162/163).

Em memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 171/173), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se, o Doutor Defensor do réu (fls. 176/177), requereu a absolvição pela atipicidade de conduta.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo laudo de fls. 40/42.

A autoria é indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu confessou a prática do delito, alegando iria usar substância entorpecente pela primeira vez, para experimentar. Confirmou, ainda, que iria dividir a droga com o amigo.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios de inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

"Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, o guarda municipal, informou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu e outro indivíduo, pegando algo através de um portão. Em abordagem, com o réu, localizaram uma porção de droga e a quantia de cinco reais. Indagado, o réu alegou que havia comprado a droga e estaria levando para o amigo Leonardo. Por fim, Leonardo confirmou que pediu para Fernando comprar a droga, pois estaria devendo para os traficantes do local.

A conduta relativa ao porte de entorpecentes para o consumo pessoal é típica e

antijurídica, não se vislumbrando violação a quaisquer princípios constitucionais, tais como o da lesividade e da intimidade.

Não é somente o uso propriamente que caracteriza o delito, mas igualmente a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para essa finalidade, sendo que o bem jurídico protegido é a saúde pública, a não apenas a saúde do usuário.

Desta forma, a alegação de atipicidade da conduta ante a ínfima quantidade de drogas, ou de inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei 11343/06 deve ser afastada. Nos termos da Jurisprudência:

"...Neste ponto não há de ser reconhecida, ainda, a alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, em virtude do princípio da alteridade. Alega o apelo defensivo que como o porte de drogas para uso não afetaria esfera jurídica outra além da do próprio agente ativo do tipo, o usuário, tal conduta não poderia ser penalmente tipificada e o respectivo artigo seria, por conseguinte, materialmente inconstitucional.

Todavia, tal alegação não procede. Não se pode perder de vista que o que é criminalizado não é o uso de entorpecente, mas sim o seu porte, que tem reflexo na coletividade e na saúde pública, bens jurídicos relevantes que extrapolam a esfera individual do usuário. Apesar das discussões na sociedade civil acerca da descriminalização de drogas, ainda é adotado, como escolha política de nosso legislativo, o modelo de tipificação penal do porte e venda de entorpecentes como meio de frear a disseminação de tais substâncias, em virtude de seus efeitos danosos que se espraiam muito além dos usuários por toda a sociedade.

Nesse sentido, o Desembargador Ary Belfort, como relator da Apelação Criminal nº 211.041-3 (Mairiporã, 4ª Câmara Criminal, 9-10-1996) - ainda na vigência da Lei 6.368/76, mas de forma completamente aplicável à legislação em vigor -, já pontuou com muita percuciência que a inconstitucionalidade do porte de drogas "parte do pressuposto errado de que haja punição para o utente. Mas não há isso em nosso país e em nosso sistema penal-típico. Usar, no Brasil, não infringe a lei especial; nem lei alguma; o que proíbe a Lei é adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio. Portanto, assegura sua liberdade individual, uso o tóxico que quiser, tanto quanto puder. Mas não guarde, não transporte consigo. Pois nestas figuras está, precisamente, o perigo à coletividade que sabiamente a Lei quis evitar" (AC 0002009-72.2012.8.26.0564, 16ª Câmara de Direito Criminal, TJ/SP, Rel. Otávio de Almeida Toledo, 04.02.2014).

No mais, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, posto que o Supremo Tribunal Federal ainda não proferiu decisão no Recurso Extraordinário 63659-SP (Tema 506), sendo, então válido e aplicável. APELAÇÃO CRIMINAL - Posse de drogas - Artigo 28 da Lei n.11.343/06 - 0,640g de maconha. Preliminar - Alegação de ilegalidade da busca pessoal - Inadmissibilidade - Diligência que atende os requisitos legais, devidamente justificada - Preliminar rejeitada. Condenação - Recurso defensivo - Pretendida absolvição - Improcedência - Materialidade e autoria delitivas demonstradas - Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares - Validade - Alegação de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas declarada quando do julgamento do RE 635.659 perante o C. STF - Inadmissibilidade - Não há que se falar em "abolitio criminis" da posse de drogas para consumo pessoal. Nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06 que apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade, mantendo hígida a figura típica - Condenação mantida - Pena de advertência corretamente fixada - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0007334-89.2017.8.26.0196; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 01/02/2019)

Não há que se falar, ainda, em aplicação do princípio da insignificância, posto que, reforça-se, o bem jurídico protegido é a saúde pública. No mais, é da própria

essência do delito que a quantidade de substância entorpecente seja reduzida.

Conforme Jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que infima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 387.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017)

“Por outro prisma, a quantidade apreendida, se pouco expressiva - 3,0g de maconha - uma porção -, não autoriza adoção do chamado “princípio da insignificância”, pois o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, saúde pública, é presumido ou abstrato. A conduta do usuário atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito em questão. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Independentemente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Recurso em habeas corpus não provido” (RHC nº 35.920 - DF, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20.05. 2014)” (AC 2016.0000238861, 2ª Câmara Criminal Extraordinária do TJ/SP, rel. Eduardo Abdalla, 12.04.2016).

Por fim, eventuais internações para tratamento não excluem a culpabilidade.

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

Desta forma, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Destarte, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

O réu é reincidente, e portador de maus antecedentes (Certidão de fls. 22/30), verificando-se a aplicação do parágrafo 4º, do art. 28, da referida Lei.

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade, prevista no inciso II, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, considerando-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP).

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu FERNANDO MARCELO DAS CHAGAS à pena de 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade, como incurso no artigo 28, inc. II, da Lei nº. 11.343/2006.
P.I.C.

Americana, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA